

1502375-72.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... consumando, assim, a prática do delito de roubo, previsto no artigo 157, §1º, do Código penal, haja vista a violência empregada de forma a assegurar a detenção dos objetos furtados para ele.

Ademais, a figura do roubo impróprio é incompatível com a tentativa, pois se ocorreu a violência o crime está consumado, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido é a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502375-72.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502375-72.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178689/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, DB5028-1/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2178689 - 01º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR DE OLIVEIRA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

ADEMIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §1º, do Código Penal.

Consta que na madrugada de 03 de julho de 2022, na Rua João Pessoa nº 184, em Santos, o réu subtraiu, para si, uma torneira, um circulador de ar, um corrimão de alumínio e cerca de oito metros de fios condutores de energia elétrica, tudo de propriedade do Supermercado Dia, e que, após a subtração, o acusado empregou violência contra Edvaldo Antonio da Silva, fazendo isso com o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa subtraída.

Consta, também, que o réu entrou no estabelecimento comercial e arrecadou os bens que desejava subtrair. Para entrar, ele arrombou umas das portas do imóvel.

Consta, ainda, que no momento em que o acusado deixou o imóvel levando os bens subtraídos, sua conduta foi observada pelo guarda municipal Edvaldo Antonio da Silva. O guarda abordou o réu para verificar o que estava ocorrendo, quando, nesse momento, pretendendo assegurar o proveito do crime e garantir a impunidade, o

acusado agrediu o guarda municipal com uma barra de metal. Não obstante, o guarda conseguiu deter o denunciado, que acabou preso em flagrante.

Consta, por fim, que os bens foram avaliados em R\$ 710,00.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 05/06). Boletim de ocorrência (fls. 14/16).

A denúncia foi recebida em 12/07/2022 (fls. 79/80).

O acusado foi citado (fls. 131/132) e apresentou resposta à acusação (fls. 149).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como o réu foi interrogado (fls. 188/189).

O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da ação. Disse, em resumo, que o réu confessou a prática do delito. Falou que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a ação do réu. Sustentou o delito restou consumado, pois o acusado estava na rua quando foi abordado, já estando na posse dos bens subtraídos. Aduziu que o réu utilizou de violência para garantir a prática delitiva, agredindo a testemunha após sair do estabelecimento vítima na posse dos bens. Afirmou que o réu possui maus antecedentes, possui personalidade voltada para a prática delito e é reincidente, devendo a pena ser aplicada além do mínimo legal. Pugnou pela aplicação do regime fechado para início de cumprimento de pena.

A Defesa, também em alegações finais, pugnou pela improcedência da ação. Falou, em síntese, que o crime deve ser desclassificado para o delito de furto tentando, pois o guarda municipal não tinha qualquer relação com a vítima, não tendo vínculo empregatício com mercado Dia, sendo apenas uma pessoa que estava passando pelo local que evitou a consumação do delito, conforme consta do artigo 301, do CPP. Disse que a subtração dos bens não se deu com o emprego de armas, grave ameaça ou violência contra pessoa, sendo incabível a condenação do acusado pelo delito de roubo. Aduziu que o acusado confessou a prática do delito. Disse que deve ser reconhecido o princípio da insignificância, sendo ínfimos os prejuízos causados, além dos bens terem sido restituídos. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e reconhecimento da atuante da confissão, bem como seja deferido o direito de recorrer em liberdade, bem como seja fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 05/06), do boletim de ocorrência (fls. 05/06), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa e atribuída ao réu.

A testemunha EDVALDO ANTONIO DA SILVA, guarda municipal, disse que por volta das 4h/4h30 estava passando pelo local dos fatos e viu a porta do estabelecimento arrombada, quando ligou para a polícia militar e para a guarda municipal para avisar sobre o ocorrido. Afirmou que, enquanto estava ao telefone, o acusado saiu do local com pertences do estabelecimento e quando foi abordá-lo recebeu um golpe de uma barra de metal, mas que mesmo assim conseguiu deter o réu até a chegada da polícia. Falou que, quando recebeu o golpe, estava na calçada em frente o mercado vítima, e o acusou acertou a sua cabeça com um saco, que tinha em seu interior uma barra de metal. Disse que ficou muito machucado com golpe, sangrando muito. Afirmou que o réu subtraiu do estabelecimento torneiras, ventilador, fiação, um corrimão e barras de metal. Explicou que o acusado estava sóbrio no momento dos fatos e que não o conhecia antes do ocorrido. Falou que estava indo para o trabalho e que estava sem farda. Aduziu que não se identificou como guarda municipal para o acusado no momento da abordagem, pois ainda não estava em serviço.

A testemunha WELLINGTON JORGE DA SILVA, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo centro, quando o COPOM informou que havia um indivíduo tentando furtar uma loja, sendo que outra pessoa havia o contido. Falou que, ao chegar ao local dos fatos, viu o réu no chão, contido por outra pessoa, quando esta se identificou como guarda municipal. Disse que o guarda municipal estava machucado com um ferimento no supercílio. Afirmou que o guarda explicou que o sujeito detido

estava subtraindo bens do mercado vítima e que o deteve. Disse que o acusado nada falou sobre os fatos e que ele estava com vários pertences do supermercado, entre eles uma barra de ferro. Afirmou que o acusado estava sóbrio e que não o conhecia antes dos fatos.

O réu, ADEMIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, interrogado em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que está arrependido do que fez, pois estava passando por necessidade. Afirmou que havia consumido drogas antes dos fatos. Falou que agrediu o guarda, pois se assustou no momento. Explicou que já foi processado e condenado anteriormente.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Em atenção aos elementos de prova carreados nos autos verifico que a responsabilização do acusado, quanto ao crime de roubo, restou plenamente comprovada.

A testemunha Edvaldo afirmou que estava passando defronte ao local dos fatos, quando verificou que a porta do estabelecimento vítima estava arrombada, momento que passou a ligar para a polícia militar e guarda municipal para informar sobre o ocorrido. Disse, também, que, logo em seguida, o acusado saiu do interior do supermercado, momento que passou a persegui-lo, quando o réu agrediu com um golpe na cabeça, causando-lhe ferimento. Explicou, ainda, que mesmo machucado, conseguiu deter o acusado até a chegada da polícia.

Desta forma, a testemunha Wellington, policial militar que atendeu a ocorrência, confirmou a narrativa da Edvaldo. Afirmou que estava em patrulhamento, quando foi avisado pelo COPOM sobre a ocorrência do delito e que, ao chegar ao local, viu o réu detido por Edvaldo e que este tinha um ferimento no supercílio. Narrou que o acusado estava com vários bens pertencentes ao supermercado vítima. Explicou, ainda, que o réu estava sóbrio e que não o conhecia antes dos fatos.

Quanto ao valor do testemunho policial, é digno de nota que o artigo 202 do Código de Processo Penal determina categoricamente que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Significa dizer que, ressalvado o disposto no artigo 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo ser levado em conta que os agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade, possuindo fé pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, inclusive, atribuiu idoneidade e presunção de veracidade à prova prestada por policiais, aduzindo, em entendimento pacificado, que “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC. nº. 74.608- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido frequentemente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto: “Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Com efeito, a idoneidade do depoimento policial só poderia ser questionada se houvesse indícios nos autos de injusta incriminação de inocentes, o que não ocorre no caso sub examine, até porque as testemunhas nem conheciam o acusado.

Destarte, da análise dos referidos depoimentos, verifica-se que as testemunhas

narraram de forma harmoniosa e convincente todo o contexto da prática delituosa, desde o momento que o acusado saiu do interior do estabelecimento, na posse da res furtiva, sendo perseguido por Edvaldo, momento que o agrediu para tentar continuar a empreender em fuga, até quando foi detido por este, sendo preso em flagrante pela polícia militar.

Ressalta-se, ainda, que o próprio acusado, em seu interrogatório prestado em Juízo, assumiu a prática delitiva, dizendo que subtraiu os pertences do estabelecimento vítima, bem como que agrediu Edvaldo quando estava em fuga.

Portanto, os depoimentos prestados pelas testemunhas, corroborados pelas palavras do réu, são suficientes para demonstrar de forma satisfatória a prática do delito de roubo pelo acusado.

Deve-se destacar, ainda, que não há motivos para duvidar dos referidos depoimentos, uma vez que nada há nos autos que demonstre que as testemunhas ouvidas em Juízo tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente o réu, ressaltando-se que sequer o conheciam antes dos fatos.

Assim, tem-se que merecem suas palavras inteira confiabilidade, máxime quando se considera que a defesa não conseguiu reunir provas que pudessem desprestigiá-las. No mais, há de se pontuar, todavia, que o delito praticado pelo acusado está previsto no §1º, do artigo 157, do Código Penal, haja vista que o acusado, logo após ter subtraído os bens do supermercado vítima, agrediu Edvaldo, de modo a evitar que ele o detivesse, restando plenamente caracterizado que empregou violência contra a pessoa, a fim de assegurar a detenção dos objetos subtraídos para ele. Assim, não merece acolhimento a tese defensiva de que o delito praticado pelo réu deve ser desclassificado para o crime de furto tentando. Nesse sentido, conforme supracitado, o §1º, do artigo 157, do Código Penal, é claro ao dispor que, após a subtração da coisa, a prática de violência contra a pessoa, de forma a assegurar a detenção dos objetos subtraídos, caracteriza a prática do delito de roubo, sendo o ocorreu no presente caso.

Desta forma, em nada altera a tipificação da conduta do réu o fato de a pessoa vítima da violência não ser a vítima direta da subtração, ou ao menos ter qualquer relação com esta, tendo em vista que aludido parágrafo não faz qualquer referência ou exigência nesse sentido.

Neste diapasão, não é necessário liame entre o ato ofensivo e a pessoa que seja possuidor, detentor ou proprietário dos bens subtraídos, podendo a violência ser perpetrada contra um terceiro, com vistas a obter o bem de outro indivíduo, como ocorreu no presente caso.

Ressalta-se, ainda, que o delito restou configurado na modalidade consumada, tendo em vista que a res furtiva foi retirada da esfera de disponibilidade da vítima tendo o acusado a posse de fato dos bens.

Sem prejuízo, ressalto que, no caso dos autos, conforme já destacado, o acusado subtraiu os bens do estabelecimento vítima, tomando posse de vários bens, momento que foi perseguido por Edvaldo, o agredindo, consumando, assim, a prática do delito de roubo, previsto no artigo 157, §1º, do Código penal, haja vista a violência empregada de forma a assegurar a detenção dos objetos furtados para ele.

Ademais, a figura do roubo impróprio é incompatível com a tentativa, pois se ocorreu a violência o crime está consumado, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. Artigo 157, §1º, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. O valor do depoimento de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Pleito de reconhecimento da forma tentada. Não cabimento. Roubo impróprio incompatível com a figura da tentativa. Momento consumativo da infração é o do efetivo emprego da violência após o agente tornar-se possuidor da coisa subtraída, com o fim específico de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, ainda que ela venha a ser recuperada em momento imediatamente posterior. Dosimetria da pena que, entretanto,

comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenação pretérita registrada há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Pena-base devolvida ao piso legal e assim mantida nas demais etapas à minguia de causas modificadoras. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Impossibilidade legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; Apelação Criminal 1501230-32.2022.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022)". Grifei.

"APELAÇÃO. Roubo impróprio. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminar. Violação à garantia da ampla defesa. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para o delito de furto. Atipicidade da conduta - aplicação do princípio da insignificância. Reconhecimento da tentativa. Dosimetria: reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 1. Preliminar. Violação à garantia da ampla defesa. Afastamento. Réu que teve a oportunidade de se manifestar quanto aos fatos atribuídos no aditamento da denúncia quando do seu interrogatório. Defesa que deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao aditamento da denúncia, mantendo-se silente na segunda audiência de instrução, debates e julgamento, bem como nas alegações finais. 2. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas pelos elementos coligidos aos autos. Declarações da vítima e depoimentos dos guardas municipais coesos e harmônicos ao longo da persecução penal. Réu preso em flagrante dentro do estabelecimento comercial vítima. 3. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Ocorrência de violência após a subtração do bem. Precedentes. 4. Pleito objetivando aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Emprego de violência comprovado. Precedentes. 5. Reconhecimento da tentativa. Réu surpreendido no momento em que executava as elementares do delito de roubo. Guardas civis que surpreenderam o réu em luta corporal com a vítima após tentar subtrair o dinheiro que estava no caixa de seu estabelecimento comercial. 6. Dosimetria que merece reparo. 6.1. Condenação anterior pelo crime previsto pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06 que não pode ser utilizada para configuração de maus antecedentes e, tampouco para caracterização de reincidência. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. 6.2. Aplicação da fração relativa à tentativa em 1/2 (metade). Conduta que percorreu razoável parte do iter criminis. 7. Possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e do quantum da pena aplicada. Incidência da Súmula nº 269, do STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastada a preliminar arguida pela defesa. (TJSP; Apelação Criminal 1500186-25.2020.8.26.0623; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)". Grifei.

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria delitivas não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Inviável a pretendida desclassificação para crime de furto, ante a demonstração do emprego de grave ameaça na forma prescrita pelo tipo. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparo. Pleito de reconhecimento da forma tentada. Não cabimento. Roubo impróprio incompatível com a figura da tentativa. Momento consumativo da infração é o do efetivo emprego da violência após o agente tornar-se possuidor da coisa subtraída, com o fim específico de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, ainda que ela venha a ser recuperada em momento imediatamente posterior. Regime inicial semiaberto bem fixado. Irrelevante a detração do tempo de prisão provisória, por não conduzir a reprimenda a patamar que pudesse ensejar o abrandamento do regime. Impossibilidade legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de sursis. Sentença mantida. RECURSO

DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1503198-51.2019.8.26.0536; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)". Grifei.

Também não é o caso acolhimento da tese defensiva de reconhecimento do princípio a insignificância, haja vista que não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância em sede de crimes que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, uma vez que indica maior reprovabilidade da conduta delituosa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. Roubo impróprio. Pleito absolutório. Fragilidade probatória. Princípio da insignificância. 1. Condenação mantida. Autoria e materialidade do crime devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu que confessou a subtração. Impossibilidade de incidência do princípio da insignificância. Inaplicabilidade da excludente de tipicidade em crimes de roubo. Precedente do STJ. 2. Dosimetria que merece reparos. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência – exasperação em 1/6. Causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistentes. 3. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena aplicada que, somada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à reincidência, permite a fixação do regime prisional mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Incabível. Crime cometido mediante grave ameaça. Réu reincidente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500128-47.2022.8.26.0592; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osvaldo Cruz - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022)". Grifei.

Ainda que o bem jurídico central alvo da tutela no crime de roubo seja o patrimônio, não é o único aspecto a ser considerado no padrão da reprovabilidade. Fosse assim, não haveria distinção deste para com o furto. Em realidade, a figura criminosa contém outras condutas que afetam outras esferas igualmente protegidas. O emprego de violência física e a grave ameaça delineiam estes outros bens que são alvo da tutela penal. Ou seja, é esta múltipla convergência de bens, reduzidos em uma única fórmula penal, que justifica o padrão punitivo mais severo fixado para o roubo.

O que se quer ressaltar é que em face desta maior complexidade ínsita ao fato, não é possível rotulá-lo de um irrelevante penal.

Ademais, os bens subtraídos não podem ser considerados de baixo valor, ressaltado o fato de que pertencem à esfera econômica do estabelecimento vítima.

Ressalta-se que, mesmo nos delitos onde é possível aplicação do princípio da insignificância, o seu reconhecimento deve se dar em situações excepcionais. É necessário o preenchimento de requisitos cumulativos, que são: mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada, consoante o exposto no HC 84.412/SP, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, situação que não se encontra presente nestes autos.

Destarte, a prevalência da tese defensiva seria um estímulo às subtrações de bens de baixo valor, razão pela qual não tem cabimento a aplicação do princípio da insignificância no presente caso.

Portanto, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou a conduta delitativa descrita na denúncia, sendo a condenação medida de rigor.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nesta esteira, deve ser levada em consideração a personalidade do agente, tendo em vista as diversas condenações criminais que o acusado possui, várias delas com relação a delitos contra o patrimônio, fazendo do crime um meio de vida, conforme se denota da certidão de fls. 100/104 e da F.A de fls. 105/119, o que demonstra possuir personalidade voltada para a prática delitiva.

Observo, ainda, que, conforme certidão de fls. 100/104 e F.A de fls. 105/119, o acusado possui maus atendentes, devendo a sua pena base também ser aumentado por tal motivo.

Com isso, tendo em vista a sua personalidade voltada para a prática delitiva e os seus maus antecedentes, majoro a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme certidão de feitos criminais de fls. 100/104 e F.A. de fls. 105/119. Dessa forma, está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Anoto ainda, que em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito descrito na denúncia, o que, em tese, impõe a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", também do Código Penal. No entanto, a reincidência é preponderante, por força do artigo 67, do Código Penal. Consoante estabelece o referido artigo, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

Contudo, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência, sucumbindo apenas perante a atenuante da menoridade.

A esse respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária - prequestionamento. PENA - DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal." (RHC 141519, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PREQUESTIONAMENTO - INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. PENA - DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal. PENA - DOSIMETRIA - SOBREPOSIÇÃO - INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição - artigos 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006." (RHC 172842, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2021 PUBLIC 26-02-2021).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas, e, portanto, aumento em mais 1/6 (um sexto) a pena fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (dias) dias de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que fixo por definitivo a pena do réu em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (dias) dias de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expresse óbice legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal).

Nos termos do artigo 33, §2º, tendo em vista a reincidência do acusado, o delito

praticado e a pena aplicada, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento da pena aplicada.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado ADEMIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §1º, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (dias) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, observando-se, quanto à pecúnia, o valor mínimo legal, ante a ausência de dados sobre sua capacidade financeira.

O réu NÃO poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões da prisão.

Neste sentido, segue posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Quinta turma firmou orientação no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.” (STJ - AgRg no HC: 645590 SP 2021/0044481-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 10/05/2021).

Recomende-se o sentenciado na unidade prisional em que se encontra recolhido. Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se o necessário para a cobrança da multa penal imposta.

Considerando que o sentenciado foi assistido por advogado dativo nomeado por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que ele se encaixa no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita isentando-o do pagamento das custas processuais. Anote-se.

P.I.C.

Santos, 06 de dezembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA